

1500647-64.2021.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... teriam trazido consigo, para fins de tráfico, sete porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2,140 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da inicial que “o denunciado e a adolescente, com intuito de praticarem o tráfico de drogas no local dos fatos, para lá se dirigiram, o primeiro na posse das drogas acima descritas, as quais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500647-64.2021.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500647-64.2021.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO FERREIRA SOUZA FRANCA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. DIEGO FERREIRA SOUZA FRANCA, qualificado a fls. 19, foi denunciado e viu-se

processado como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 20 de novembro de 2021, por volta de 20h40min, na Rua 17-B nº 1.218, Centro, nas proximidades da Creche Nilce Fugio Akashi e do Centro Esportivo Valdemar Moreira, nesta cidade e Comarca, juntamente com a adolescente J.A.M.L., conluiados e mediante unidade de desígnios, em ocasião de calamidade pública teriam trazido consigo, para fins de tráfico, sete porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2,140 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da inicial que “o denunciado e a adolescente, com intuito de praticarem o tráfico de drogas no local dos fatos, para lá se dirigiram, o primeiro na posse das drogas acima descritas, as quais transferiu para a adolescente guardar consigo.

Policiais militares receberam, então, a informação de que um casal estava realizando a venda de drogas no endereço acima mencionado, um bar, oportunidade em que para lá se deslocarem.

Ao avistar a viatura policial, o denunciado empreendeu fuga, dispensando ao solo três pinos vazios, sendo, porém, alcançado pelos militares.

A adolescente, por sua vez, começou a chorar e deixou um pino cair ao chão, instante em que, indagada, retirou da região dos seios outros seis pinos contendo cocaína, além da quantia de vinte e três reais em dinheiro.

Durante a abordagem, a jovem disse aos policiais que de fato realizava o tráfico de entorpecentes.

Já no interior da viatura policial, o denunciado dispensou um pino vazio”.

A denúncia encartada a fls. 129/132 foi recebida em 7 de dezembro de 2021 (fls. 134), sendo o Réu citado (fls. 146), apresentando defesa preliminar (fls. 151/154), rejeitada (fls. 156/157). Durante a instrução foi colhida prova oral, bem como interrogado o Réu (fls. 204/214).

Em memoriais o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denuncia (fls. 202/203).

A douta Defesa, por seu turno, requereu a improcedência da ação, sustentando a inexistência de prova da traficância, sendo que ele é usuário de drogas, motivo ao qual requereu, subsidiariamente, a desclassificação para o tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06. Em caso de procedência da ação, pediu fixação da pena no piso, com regime diverso do fechado, afastando a causa de aumento de pena do inciso III (fls. 215/220).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/09), boletim de ocorrência de fls. 11/14, auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, auto de apreensão de adolescente (fls. 34/36, auto de constatação de fls. 39/41, relatório de investigações de fls. 122/123, comprovante de depósito de fls. 124, pelo laudo de exame químico-toxicológico a fls. 142/144, além da prova oral colhida durante a instrução.

A autoria é certa contra o Réu que em Juízo negou o teor da acusação, sustentando que no dia dos fatos tinha saído do bar e foi à noite para falar com um amigo, estava com R\$ 100,00 e, com isso, adquiriu cinco porções de cocaína, encontrando-se com sua esposa do lado de fora e começaram a discutir porque ela tirou sua droga, oportunidade em que a polícia passava e, por isso, saiu correndo porque ficou com receio de ser atropelado, tendo utilizado uma porção de cocaína e guardado o pino no pé, ao passo que com a adolescente se encontrava a droga que ela havia lhe

tirado, afirmando que na delegacia disse que tinha entregado a droga para a jovem guardar porque estava sob efeito de droga e álcool. Ademais, é usuário de crack, cocaína e maconha, mas não a adolescente e está desempregado (fls. 212/214).

Sua versão não convence e restou isolada nos autos, sendo que, caso verdadeira, faria prova de suas alegações, ônus que lhe competia, com fundamento no artigo 156 do Código de Processo Penal.

A adolescente J.S.P., na fase inquisitorial disse que estava no bar com o Réu para comer, quando policiais chegaram e ele fugiu. Indagada, inicialmente disse que não carregava droga, mas quando ficou sabendo que uma policial feminina faria revista acabou por confessar que estava com a droga, entregando os pinos de cocaína, dizendo que “pega um malote de 15 pinos no valor de R\$ 150,00, para vender cada pino pelo valor de R\$ 10,00, ficando com R\$ 50,00”, sendo que estava vendendo droga porque foi colocada para fora de casa (fls. 08). Em Juízo, a fls. 204/205, esclareceu que o Réu lhe entregou a droga, o que lhe incomodava, não se recordando por quanto vendia o entorpecente.

O policial militar Rogério, que prestou depoimento em fls. 206/208, declarou que no dia dos fatos receberam uma denúncia de que uma mulher de roupa cor-de-rosa estava traficando no bar, para lá se dirigindo, tratando-se de um conhecido ponto de venda de drogas e quando se aproximavam do local o Réu, que estava sentado no bar, correu e virou o quarteirão, sendo acompanhado por outra viatura e abordado. No bar viram a adolescente com características idênticas à da denúncia e ao se levantar ela deixou cair um pino de cocaína, sendo que indagada acabou por confirmar que carregava mais droga e a entregou aos policiais, dizendo que estavam fazendo a traficância porque passavam necessidade, ao passo que o Réu, que somente estava com pino vazio, declarou que sua esposa estava com o entorpecente, mas a droga não seria dele, ele que fazia a venda, tendo corrido porque acreditou que era procurado por ter incendiado um veículo na escola. Por fim, disse que era local próximo de uma creche e de um centro esportivo e nenhum deles aparentava estar sob efeito de droga, não os conhecendo dos meios policiais. No mesmo sentido o depoimento do policial militar Marcelo, em fls. 209/211, que por sua vez disse que a adolescente não era conhecida, mas o Réu sim, por furto e tráfico.

A conduta do Acusado indica que no dia, horário e local apontados na denúncia, juntamente com a adolescente, traziam consigo porções de cocaína, denotando claramente a narcotráfica. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente a quantidade de droga apreendida, a forma como estava disposta em porções individuais, o fato de ser conhecido dos meios policiais pelo tráfico de drogas, sua tentativa de fuga ao perceber a presença dos policiais, assim como as declarações claras da adolescente, sua companheira, dando informações precisas da forma como era explorada pelo Réu na traficância, além do dinheiro sem origem lícita encontrado. Tais condutas apontam, indubitavelmente, que o Réu utilizava o entorpecente apreendido consigo para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006.

Importante destacar que o simples fato de ser usuário de drogas – sequer comprovado - não inibiria a conduta do narcotráfico, sendo que, muitas vezes, tais condutas caminham juntas, o que impede a desclassificação pretendida.

Quanto ao depoimento prestado por policiais, é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, tanto que arrolados em comum pela Defesa, motivo porque não podem ser descartados, notadamente porque o Réu não ofertou qualquer resistência ao depoimento deles.

A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, “Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm

convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram" (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória, sendo que prova da mercantilização não é necessária para a prática do crime, quando presentes os requisitos comprobatórios do tráfico, como na hipótese em julgamento. Oportuno salientar, neste panorama, que "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Por fim, bem demonstrado que o Réu praticou o crime envolvendo uma adolescente (cf. fls. 34/36) e explorava a traficância nos arredores de uma creche e de um centro esportivo (fls. 122/123), observando-se que sua periculosidade na prática deste crime é tamanha que, segundo declarações dos autos, ele teria incendiado o veículo de uma professora na porta da escola.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O Réu não ostenta antecedentes criminais certificados nos autos que possam ser considerados para exasperação da pena base e apreciando os parâmetros legais ditados pelo artigo 59 do Código Penal, onde não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, verifico que deve a pena base ser fixada no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor, à minguia de comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase da dosimetria da pena, aumento-a em 1/3 (um terço) em razão da reincidência (fls. 195/196), atingindo o patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Por outro lado, rejeito a pretensão de majoração da pena com base no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque não há qualquer indicação de que tenha o Réu se aproveitado da pandemia para praticar o crime de tráfico, não se verificando relação direta deste período de exceção com a prática do ilícito, não se podendo admitir interpretação extensiva a ponto de se exacerbar a condenação somente pelo momento em que praticado o delito, sob pena de se tornar padrão para todo e qualquer crime praticado durante o tempo em que grassar a peste. Nesse diapasão: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE PÚBLICA. CONTEXTO DE PANDEMIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MAUS

ANTECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.

1. Quando a quantidade ou a variedade da droga não é significativa, não há falar em exasperação da pena-base, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade.

2. A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito.

3. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige que o paciente seja primário e de bons antecedentes, condição essa não preenchida pelo paciente.

4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 530 dias-multa, à razão mínima, pelos fundamentos declinados" (STJ, HC 654.255/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25.05.2021 - grifei).

Em vista da incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, posto que se comprovou que ele vendia os entorpecentes nas imediações de uma escola, de uma creche e ainda envolveu uma adolescente, majoro sua pena em 1/2 (metade) e a fixo em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 999 (novecentos e noventa e nove) dias-multa, em seu piso legal.

Sendo reincidente e portador de maus antecedentes, o Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que não há prova de ocupação lícita, além do fato de ser conhecido dos meios policiais pelo tráfico, crime equiparado ao hediondo, demonstrando que se dedica, exclusivamente, à atividade criminosa do comércio de drogas. Dessa maneira, torno aquela pena definitiva, ante a inexistência de demais causas legais modificadoras.

Importante consignar que caberia à defesa a prova de que o Acusado faria jus à causa de diminuição acima mencionada, considerando-se que esta não é automática e somente de aplicação possível quando presentes os requisitos legais, forte no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, ou seja, "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer". Desta forma, o Réu deveria indicar, através de provas robustas que trabalhava e não se dedicava a atividades criminosas, afastando o quanto foi comprovado pela acusação, isto é, que estava em ato de traficância.

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado a hediondo e ser o Réu portador de maus antecedentes e reincidente, é o inicial fechado. Por outro lado, é vedada a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis, pela ausência do requisitos objetivo e subjetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Ressalto, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um "pequeno" traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada à crime delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: "Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012). E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela

infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizado quantia em dinheiro sem comprovação de regularidade em seu recebimento, evidenciando-se ser o numerário fruto da venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda dos valores apreendidos com o Réu, depositados em Juízo (fls. 124), que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência, CONDENO o Réu DIEGO FERREIRA SOUZA FRANCA, qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 999 (novecentos e noventa e nove) dias-multa, em seu piso mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedada a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis. No mais, decreto a perda do dinheiro apreendido com ele, depositado a fls. 124, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) e encaminhe-se o numerário apreendido a fls. 124 em favor da União.

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado em razão da equiparação à hediondez do crime, o Réu, descontente com a decisão, deverá aguardar o julgamento do recurso preso, motivo por que mantenho sua prisão cautelar, sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nada justificando que, preso em flagrante, fosse posto em liberdade depois de condenado por crime equiparado ao hediondo, em especial diante de seus maus antecedentes.

São devidas custas na forma da lei, delas ficando o Réu isento por ser beneficiário da Justiça Gratuita, pedido que ora defiro uma vez presentes os requisitos legais.

P.R.I.C.

Guaíra, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA